

東京地方裁判所民事第 2 部 C 係 御中

意 見 書

平成 1 9 年 5 月 3 日

立命館大学大学院法務研究科教授
博士（法学・一橋大学）

三木 義一

はじめに

本意見書は、本件の中心的争点の1つである原告の多重債務者に対する着手金の収入計上時期について、税法学の研究者として、できるだけ公正に意見を述べるものである。

I 被告の主張とその基本的誤り

被告の主張

この争点についての被告の主張は、次の第1準備書面の記述に集約される。

所得税法27条2項は、「事業所得の金額は、その年中の事業所得に係わる総収入金額から必要経費を控除した金額」と規定し、同法36条1項は、所得金額計算の前提となる収入金額について、「その年分の各種所得の金額の計算上収入金額とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、その年において収入すべき金額(金銭以外の物又は権利その他経済的な利益をもって収入する場合には、その金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額)とする。」と規定する。同項の「収入すべき金額」とは、実現した収益、すなわち、まだ収入がなくても「収入すべき権利の確定した金額」をいい、いわゆる権利確定主義を採用したものであり、「権利確定主義における『収入すべき権利の確定する時期』とは、個別の契約による債務の弁済期ではなく、私法上特別の約定のない場合に収入し得る時期を意味する」と解されている(金子宏「租税法(第十一版)」253、254ページ)。

【被告第1準備書面14頁】

被告の主張で注目すべき点は、収入すべき金額＝「実現した収益」とし、権利「発生主義」的な権利確定主義を現行法が採用していないことを認めている点である。

この点は、本件の問題を検討する場合の非常に重要な出発点である。

したがって、被告の主張に従っても、本件着手金については当該収入金額が何時「実現」したといえるかの解釈になるが、被告は、そのあとで通達36-8の(5)を引用し、次のように着手金は着手時だと断定して、いつの間にか、権利「発生主義」的理解にすり替えて本件更正処分を合理化している。

(1) 着手金等について

ア 着手金の収入計上時期について

原告の所属する横浜弁護士会報酬規程(以下「報酬規程」という。乙第 1 号証)によれば、弁護士報酬の「着手金」とは、「事件又は法律事務の性質上、委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて、その結果のいかんにかかわらず受任時に受けるべき委任事務処理の対価」とであるとされ(報酬規定 3 条 2 項)、また、着手金は、事件等の依頼を受けたとき支払を受けるものとされている(同 4 条、なお、日本弁護士連合会の報酬等基準規定 4 条も同様に規定している。甲第 1 0 号証 1 3 ページ参照)。

そして、原告は、依頼者との間で、民事事件又は刑事事件等の処理に関する委任契約(以下「事件委任契約」という。)を締結し、当該契約において、依頼者は、原告に対して、着手金を支払うものとする旨の合意をした(甲第 1 1 号証「民事事件委任契約書」及び甲第 9 3 条の 1「刑事事件委任契約書」の各第 3 条、甲第 1 3 号証「契約書」2 項等)。

以上によれば、原告は、事件委任契約に基づき、受任時(当該契約締結時)において、依頼者に対して当該委任契約において定められた着手金の全額を請求する権利を確定的に取得するというべきであり、権利確定主義に照らして、着手金の金額は、当該契約締結日の属する年分の収入金額に算入されなければならない。

つまり、委任契約締結時に「確定的に」着手金を取得していると主張していることになる。しかし、この被告の主張は重大な欠陥がある。

着手金は、確かに、事件の依頼を受けたときに支払を受けることとされているが、同時に委任事務が途中で終了した場合の返還規定があり、「委任契約に基づく事件等の処理が、解任、辞任又は委任事務の継続不能により、途中で終了したときは、弁護士は、依頼者と協議のうえ、委任事務処理の程度に応じて、受領済みの弁護士報酬の全部若しくは一部を返還し、又は弁護士報酬の全部若しくは一部を請求する」(報酬規定 4 4 条)ようにしなければならないものである。つまり、委任事務を終了した場合には、「その(委任事務の)結果のいかんにかかわらず受任時に受けるべき」着手金の帰属は確定するが、委任事務終了までは返還の可能性も高く、受任時に受け取る金額は委任事務遂行の前受金とされているのである。つまり仮に契約時に全額支払われたとしても、その基本的性格は委任事務に対する対価の前払いであり、自己の収入金額にする権利自体が確定しているとはいえないものである。

もちろん、このような規定内容になっている場合でも、被告のような主張が可能になる場合があるが、その場合とは、原告が着手金全額を現実に受け取っており、しかも、中途返還の実態がほとんどないような場合である。このような場合は、権利確定主義ではなく、いわゆる管理支配基準が適用されることがあるからである。

しかし、本件は、そもそも契約時に着手金が入金されている事案ではない。それどころか、多重債務者達の破産処理事務であり、通常の事件以上に収入金額実現の可能性が乏しい事案である。被告の前記主張は着手金一般についての説明としても問題であるが、本件の争点となっている多重債務者の依頼を受けた弁護士の着手金の帰属時期の理解としては全く根拠のない誤った主張である。多重債務者は、2007年3月3日に「自死をなくす会」の設立総会が神戸市で発足したこと(2007年3月4日付朝日新聞朝刊34面)からも推測できる状態にある人々である。このような多重債務者のために受任した場合の着手金を報酬規定の一部のみから強引に「発生主義的」権利確定主義に結びつけ、結果として権利確定主義の具体的適用を誤った結論を導いているといわざるを得ない。その点を少し、わかりやすく説明してみたい。

Ⅱ 「収入すべき金額」の意味

まず、所得税法は「権利確定主義」を何ら明文で定めたことはなく、一貫して「収入すべき」金額と規定してきたことは周知の事実である。この「収入すべき金額」の意味が「権利確定主義」であると理解された直接の根拠は、昭和26年に制定された旧所得税法基本通達(以下、「旧通達」と略す)であり、同通達が「収入金額とは、収入すべき金額をいい、収入すべき金額とは収入する権利の確定した金額をいう」(旧通達194)と規定していたからである。同時に旧通達は、事業所得について、「原則として、収入すべき金額の基礎となった契約の効力発生の時期」(旧通達198)と規定していたため、この権利確定主義は発生主義会計の初期の素朴な発生主義的な理解がなされ、「権利発生主義的」権利確定主義として運用され、初期の判例もこれにしたがっていたと言ってよい。

しかし、企業会計においても発生主義会計が素朴な発生のみを基準にしていたものから、「実現」概念を発展させ、単に発生だけではなく、当該収益が実現したといえる段階になってはじめて収益を計上すべきとする発生主義会計へと発展していったのである。現金の実際の受入を基準とするものではないので、現金主義ではなく、発生主義ではあるが、「実現」の要素を重視することによって、その取引の個別性や実態に応じた収益認識の可能性を認めるようになったのである。

こうした企業会計の変化も考慮して、所得税の取扱でも実質的に大きな修正が昭和45年に行われたのである。

国税庁の職員らで執筆されている『注解所得税法』は次のように説明している。

さて、今日でも権利確定主義が税法の原則であるかのようにいわれるのが一般であるが、実は、国税庁は昭和45年に旧通達に代って新しく制定した現行基本通達では権利確定主義の旗印をおろしてしまったのである。

すなわち、前述した権利確定主義なる用語の淵源となった旧所所得税基本通達194を継承した内容の通達はもはやなく、現在では、国税庁通達は「収入金額とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額は、その収入の基因となった行為が適法であるかどうかを問わない。」(所基通36-1)旨を定めるとともに、各種所得ごとに収入金額の計上の時期についての税務執行基準を明らかにしているにすぎない。もう少し具体的にいうと、旧通達は収入金額の年度帰属の時期について、まず「権利確定主義」をその原則として宣明するとともに、その原則の下で各種所得についてその権利確定の時期に関する解釈を具体的に明らかにするという構成を採っていたのに対し、現行通達では、そのような統一的原則の明示がなく、単に各種所得ごとにその収入金額の計上時期を示すにとどまっている。しかも、その内容の面でも、旧通達が、権利確定主義の解釈として事業所得、山林所得、譲渡所得等について「契約の効力発生の時」ないし「所有権等の移転の時」を基準としていたのに対し、現行通達はこれらの所得について原則として「資産の引渡の日」を基準としている。つまり、この点で現行通達は、もはや「権利確定主義」すなわち「権利確定」という法的側面に注目して収入金額の年度帰属の時期を決める考え方から訣別した内容となっているのである。

【注解所得税法(4訂版)(大蔵財務協会・871頁)】

このような見解は、国税関係者に共通の理解であり、例えば、元大蔵省の西野氏と大島氏も所得税法36条の意義について次のように解説しているのである。

西野 まず36条の収入金額ですが、重要なのは第1項です。ここでは収入金額あるいは総収入金額は、別段の定めがある場合を除いてその年において収入すべき金額だといっています。この「収入すべき金額」の解釈として所得税法の旧基本通達は「収入する権利の確定した金額をいうものとする。」とっていました。この解釈が権利確定主義とよばれて多くの論争の種となったことは周知のとおりです。

しかし現在の通達は権利確定主義の立場に立っていません。いや、その立場に立っていないというより、各種所得の収入計上の時期についての一般的原則を掲げることをやめてしまって、総論としては単に違法行為に基づく収入も課税すべき収入だというに止まり(基通36-1)、あとはいきなり各論に入って所得の種類、態様に応じた収入計上の時期を示しているわけです。

大島 旧通達がもつたゆきを失ったのは亦に堅明な一とであつたと用いま

大島 私は現通達がそんなゆき方をしたのは大変に賢明なことであったと思います。・・・というそれでは無原則か、ということになるわけですが、1つの原則ですべてを律することはできないとしても、基本となるポイントというのはいくつかあるわけです。例えば、

①世の中の常識(難しくいえば公正な慣行といってもよいでしょう)にあっているか。

②所得として最終的に実現する見込みは極めて高いといえる段階にまで到っているか。

③資金的に見て納税し易い状態に達しているか、逆に納税の時期を失することはないか'

④租税回避を誘発することはないか。

⑤納税者、税務官署、双方の側にとって事務的に負担をかけすぎることはないか、実行し易いか。

⑥基準としてあいまいではないか・外形的にこつかみ易いか。

こういったことを総合勘案して具体的な収入の性格に応じた時期を定めるしかないんじゃないでしょう。いまの通達はそうした態度であると思います。そしてくり返すようですがこうした考え方を名づけて何主義というのか、名前はいつでもよいというよりむしろなくもがないという気がします。

【大島隆夫・西野襄一『所得税法の考え方・読み方』(税務経理協会・1986年)289頁以下】

このような変遷を経て、現行の所得税法の基本通達が成立していることにまず留意しなければならない。現行の実務上の取扱を見る限り、単純な発生主義的権利確定主義ではないことは、次の事業所得の取扱(所得税法基本通達36-8)を見ても明らかである。

事業所得の総収入金額の収入すべき時期は、別段の定めがある場合を除き、次の収入金額については、それぞれ次に掲げる日によるものとする。

(1) 棚卸資産の販売(試用販売及び委託販売を除く。)による収入金額については、その引渡しがあった日

(2) 棚卸資産の試用販売による収入金額については、相手方が購入の意思を表示した日。ただし、積送又は配置した棚卸資産について、相手方が一定期間内に返送又は拒絶の意思を表示しない限り特約又は慣習によりその販売が確定することとなっている場合には、その期間の満了の日

(3) 棚卸資産の委託販売による収入金額については、受託者がその委託品を販売した日。ただし、当該委託品についての売上計算書が毎日又は1月を超えない一定期間ごとに送付されている場合において、継続して当該売上計算書が到達した日の属する年分の収入金額としているときは、当該売上計算書の到達の日

(4) 請負による収入金額については、物の引渡しを要する請負契約にあってはその目的物の全部を完成して相手方に引き渡した日物の引渡しを要しない請負契約にあってはその約した役務の提供を完了した日。ただし、一の契約により多量に請け負った同種の建設工事等についてその引渡数量に従い工事代金等を収入する旨の特約若しくは慣習がある場合又は1個の建設工事等についてその完成した部分を引き渡した都度その割合に応じて工事代金等を収入する旨の特約若しくは慣習がある場合には、その引き渡した部分に係る収入金額については、その特約又は慣習により相手方に引き渡した日

(5) 人的役務の提供(請負を除く。)による収入金額については、その人的役務の提供を完了した日。ただし、人的役務の提供による報酬を期間の経過又は役務の提供の程度等に応じて収入する特約又は慣習がある場合におけるその期間の経過又は役務の提供の程度等に対応する報酬については、その特約又は慣習によりその収入すべき事由が生じた日

(以下、略)

冷静に読めば、これらは抽象的な法的権利発生だけでは収益を認定せず、より具体的な実現の基準を求めていることがわかる。

つまり、権利確定主義といっても、よく誤解されるような抽象的・法的な権利関係の発生時期で課税することを前提としているのではなく、発生主義の発展を受けて「実現の」の時期を重視して「収入すべき」金額の有無を判断しており、元大蔵省の植松守雄氏の次の指摘のように理解されねばならないのである。

今日でも惰性的に、税務の基準は「権利確定主義」という説明が、広く行われている。しかし、新基準の内容は、全くその呼称にふさわしくなく、しいて名称をつけるとすれば、所得税についても「実現主義」の語を使う方が無難のように思われる。

【植松守雄「収入金額（収益）の計上時期に関する問題」租税法研究 8 号 5 0 頁】

このことをまず、きちんとおさえておかないと、本件の着手金についても誤った判断を導くことになる。

Ⅲ 本件着手金の帰属時期

本件着手金について、被告は着手時に計上すべきことを主張し、前記のように、その根拠を次の通達に求めている。

【所得税法基本通達 36 - 8】

(5) 人的役務の提供(請負を除く。) による収入金額については、その人的役務の提供を完了した日。ただし、人的役務の提供による報酬を期間の経過又は役務の提供の程度等に応じて収入する特約又は慣習がある場合におけるその期間の経過又は役務の提供の程度等に対応する報酬については、その特約又は慣習によりその収入すべき事由が生じた日。

しかし、この通達から、何故本件のような課税処分が肯定されるのか、全く不明である。むしろ、この取扱を前提にするなら、次のように解さねばならないはずである。

まず、人的役務の提供は、弁護士業務の場合も、役務提供を完了した日となるのが原則である。

この原則に対する例外として「期間の経過又は役務の提供の程度等に応じて収入する特約又は慣習がある場合に」は「その特約又は慣習によりその収入すべき事由が生じた日」になるが、その場合でさえ、受け取った金額全額を収入金額とするのではない。

このような自己の通達上の取扱すら無視して、弁護士の着手金については、契約時段階で課税していることになる。そのことが許されるのは、着手金を現実に受け取り、返還の実態がほとんど存在していない場合、いわゆる管理支配基準を適用できる場合だけであるが、本件の場合とは異なる。

もう一つの被告側の論拠として、本件着手金は着手時に確定的に帰属しており、前受金ではないとする主張も考えられるが、そうであるならば委任事務であるのに、委任終了前に帰属が確定する法的論拠を示さなければならないが、なんら説得的な論拠が示されていない。

その意味で、被告の主張はそもそも前提を誤っているが、それだけではなく、本件は多重債務者の破産処理に係わる契約である。この場合は着手金を通常の事件のように取得するのは著しく困難であることは容易に推測されよう。このような多重債務者のために、弁護士の多くが分割払いを認めているのが実態であり、このことは原告作成の弁護士達へのアンケートからも明確に窺える。着手金、とりわけ多重債務者から委任事務のための着手金の収

入帰属年度を検討するために、何時の時点で権利が実現したといえるかは、このような弁護士達の委任契約の実態も重要な判断要素にしなければならない。

IV 原告の事案と「収入すべき」時期

以上のような、所得税法の基本的な仕組みを前提として、本件原告の着手金の帰属時期を整理しておきたい。

まず、着手金については、以上のように、役務提供完了時が原則であり、それを否定するのであれば、契約時に必ず受け取り、ほとんど返還してない、などの実態の証明が必要であり、権利確定主義ではなく、管理支配基準を根拠にしなければならない。

しかし、多重債務者に対する委任事務の実態を検討すれば、延払条件付役務提供契約ともいべき実質を有した契約を締結し、その条件自体が履行されない割合が非常に高いことがアンケートから示されている。

こうした実態と権利実現主義の意義及び報酬規定を総合的に検討すると、現行法の解釈としては、多重債務者からの委任事務に係わる収入金額の帰属時期は、回収可能時若しくは役務完了時であり、いずれにしても契約時ではあり得ないといえよう。なお、原告は多重債務者との間では分割特約を付しているのも、この特約によりその収入すべき事由が生じた日を帰属時期とすることも合理的な解釈といえよう。

なお、このような解釈はいわゆる現金主義そのものではなくて、権利実現の時期を、多重債務者との契約に基づいて回収が具体的に可能になる時点若しくは役務完了時点になると解している主張であり、権利確定（実現）主義に基づく主張である。

なお、弁護士のような非商人の場合は取引の実態からすれば、「収入すべき金額」を現金主義的に判断することも不合理ではなく、むしろ実態により適合的であることにも留意すべきであろう。

強調しておきたいことは、多重債務者の実情とその救済に努力することを税法の形式的解釈によって阻害することがあってはならない、ということである。もともと、収入の帰属時期の問題は、特殊なケースを除けば、租税回避とは関係なく、どの時期に課税するかどうかだけの問題であり、国庫に損害をもたらすものではないのである。したがって、帰属時期の問題は課税に支障のないかぎり、当事者が行っている行為に適合的なものにし、少なくとも社会正義に反するような結果をもたらしてはならないのである。

にもかかわらず、着手金契約があるということだけで、極めて形式的な発生主義的に収益を認識して課税するのであれば、弁護士は契約自体を躊躇せざるを得なくなり、重債務者の再生が阻害され、弁護士や司法へのアクセスを阻止することとなり、社会正義が損なわれ、広い意味において司法権に対する侵害にもなりかねないのである。

財政的に破綻している多重債務者との契約であることを適切に考慮すべきことを、最後

に強調して本意見書を終えたい。

【意見書作成者の略歴及び主要著書】

一 略歴

昭和25年生まれ

昭和48年 3月 中央大学法学部卒業

昭和50年 3月 一橋大学大学院法学研究科公法専攻修士課程修了

昭和50年11月 同博士課程中退・日本大学法学部助手

昭和55年 4月 静岡大学人文学部法学科専任講師

昭和55年10月 同 助教授

平成 4年 4月 東京大学社会科学研究所助教授併任

(5年3月まで)

平成 5年 3月 法学博士(一橋大学)

平成 5年 4月 静岡大学人文学部法学科教授

平成 6年 4月 立命館大学法学部教授

平成16年 4月 立命館大学大学院法務研究科教授(学部も併任)

現在に至る

(なお、平成10年4月～10月 ミュンスター財政裁判所客員裁判官)

(平成18年4月～ 北京大学客員教授)

二 主要著書

『よくわかる税法入門(第3補訂版)』(有斐閣、2007年)

『実務家のための税務相談(民法編)(第2版)』(有斐閣、2006年)

『日本の税金』(岩波新書、2003年)

『相続・贈与と税をめぐる判例総合解説』(信山社、2005年)

『日韓国際相続と税』(加除出版・2005年)

『世界の税金裁判』(清文社・2001年)

等多数有り。

学術論文や税法判例研究等多数有り。

意 見 書

被告の主張と権利確定主義

2007年8月30日

立命館大学大学院法務研究科教授
博士（法学・一橋大学）

三 木 義 一

はじめに

私が提出した5月3日付意見書（＝以下において、「第1次意見書」という）に対して、被告から7月19日付の準備書面（7）において反論をいただいた。この反論において、被告は自己のそれまでの主張の誤りを一部自白すると同時に、誤った反論もされているので、本意見書で、再度、被告・課税庁が前提としてきた権利確定（実現）主義の考え方を具体化しておきたい。

一 被告の反論とその誤り

まず、私の意見書に対する批判からお答えしておきたい。被告は、私の引用の仕方が一部のみを引用するもので、適切さを欠くとして次のように批判されている。

三木義一教授作成の意見書(甲第 180 号証、以下「三木意見書」という。)は、注解所得税法(四訂版)871 ページの「現行通達は、もはや「権利確定主義」(中略)から訣別した内容となっているのである。」などとする記載を引用し、あたかも現行の所得税基本通達が権利確定主義を採用していないかのように述べている(同意見書 4 ページ)。しかし、前掲注解所得税法は、当該引用部分に続いて、「それでは、新旧通達の間で収入金額の年度帰属の判断について、このように大きな変更が加えられたのは何故なのか。その大きな理由の一つとして違法所得に対する考え方の変遷があった。」として、所得税基本通達の改正において権利確定主義を宣明する表現を削除した大きな理由は、違法所得であっても収入金額とするためであったことを明らかにした上で、最終的には、「以上のような通達の変更があっても、(中略)税法が一般的に収入の年度帰属の時期について会計学上の「発生主義」ないし「実現主義」の立場に立っており、現行通達の内容がそのような考え方の枠内にあることには相違ない。」(前掲注解所得税法 872 ページ)としているのである。三木意見書は、上記部分を引用することなく一部のみを引用するものであるから、同意見書の記載は適切さを欠くというほかない。

【被告準備書面（7）5頁】

現行の通達が「権利確定主義」の用語を削除し、契約を締結した時点で権利確定とする発生主義的な考え方とは大きく異なるものになったことは否定のしょうがなく、私の意見書はそのことを裏付けるために財務省の方々の書かれたものを引用したのである。被告は

これに対して、「以上のような通達の変更があっても、(中略)税法が一般的に収入の年度帰属の時期について会計学上の「発生主義」ないし「実現主義」の立場に立っており、現行通達の内容がそのような考え方の枠内にあることには相違ない。」という部分を抜いており、一部のみを引用しているもので適切ではない、とされているのである。

しかし、そういうなら、被告意見書はその後に次の文章もあることも指摘すべきであった。

しかし、かつて「税法は発生主義の解釈として権利確定主義を採る」といわれたような意味での「権利確定主義」の考え方は、現行通達ではもはや姿を消しており、今日、なお税務執行に関し一般に「権利確定主義」という語が用いられているのは、いわば従来からの惰性にすぎない。

【注解所得税法(四訂版)87 2 ページ】

私が意見書で主張したかった点もこの点であり、権利確定主義の意味内容を実現主義の要素を十分加味して判断すべきことを実務も要求しているのだ、ということである。

いずれにせよ、この文章を抜いた前記反論は、被告意見書の批判がそのまま被告意見書自身への批判になることを意味している。

被告の主張は権利確定主義ではない

次に、被告は着手金について、権利確定主義を論拠に本件課税処分を肯定してきた。被告準備書面(1)では次のような記述になっている。

(1) 着手金等について

ア 着手金の収入計上時期について

原告の所属する横浜弁護士会報酬規程(以下「報酬規程」という。乙第1号証)によれば、弁護士報酬の「着手金」とは、「事件又は法律事務の性質上、委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて、その結果のいかんにかかわらず受任時に受けるべき委任事務処理の対価」とであるとされ(報酬規定3条2項)、また、着手金は、事件等の依頼を受けたとき支払を受けるものとされている(同4条、なお、日本弁護士連合会の報酬等基準規定4条も同様に規定している。甲第10号証13ページ参照)。そして、原告は、依頼者との間で、民事事件又は刑事事件等の処理に関する委任契約(以下「事件委任契約」という。)を締結し、当該契約において、依頼者は、原告に対して、着手金を支払うものとする旨の合意をした(甲第11号証「民事事件委任契約書」及び甲第93条の1「刑事事件委任契約書」の各第3条、甲第13号証「契約

書」2項等)。以上によれば、原告は、事件委任契約に基づき、受任時（当該契約締結時）において、依頼者に対して当該委任契約において定められた着手金の全額を請求する権利を確定的に取得するというべきであり、権利確定主義に照らして、着手金の金額は、当該契約締結日の属する年分の収入金額に算入されなければならない。

【被告準備書面（1）16～17頁、及び21頁】

このように、被告は弁護士報酬規定を根拠に着手金についても法的権利の確定があったとしていた。ところが、今回提出された準備書面では、この権利確定主義の主張が誤りであったことを自白し、その論拠を慣習基準に切り替えている。

弁護士、税理士等の報酬は、原則として、その仕事の完了した目に収入金額として計上すべきであるが、毎月受ける顧問料、料金のように支払日があらかじめ定められているものはその日、また、弁護士の着手金のように着手時に支払われるものが慣習となっているものについては、その時の収入金額として計上すべきものである。

そして、原告は、着手金を契約時に全額を受領する慣習が存在しないことから、上記通達のただし書にいう「特約又は慣習」に該当しないと主張するが、日本弁護士連合会のホームページ(乙第29号証)において、「着手金は弁護士に事件を依頼した段階で支払うもので、事件の結果に関係なく、つまり不成功に終わっても返還されません。」と説明されているとおり、弁護士は依頼者から着手金を事件委任契約時に全額受領することが慣習として存在するというべきである。

つまり、ここでは着手金は弁護士会の慣習上契約時に受け取ることになっているという主張になっているのである。

「慣習」基準は権利確定主義がいう、如何なる意味での「法的権利」が確定しているというのだろうか。慣習基準は、権利確定主義ではなく、事実上の慣行を重視した基準である。そして、このような基準を本件に適用する場合は、権利確定主義ではなく、法的権利は確定していないが、事実上受けとり、返還していない以上、受け取った時点で収入金額に算入すべきである、という主張になる。これは「権利確定主義」ではなく、「管理支配基準」であり、法的権利関係の確定ではなく、事実上の支配関係の形成時点を基準とする主張である。

被告は、当初は弁護士会の報酬規定に基づく権利確定主義で着手金の収入帰属時期を根拠づけていたが、今回慣習基準に切り替えている。当初の権利確定主義の主張が誤っていたことを自白していたことになる。

また、慣習基準が妥当するとしても、それは法的権利の確定ではないから、収入金額に算入できるのは、慣習に従って原告が着手金を現実に受領している場合でなければならない。本件の場合は、現実には契約時において受領はしていないのであるから、慣習基準で本件課税処分を根拠づけることもできない。

他方で、被告準備書面は慣習基準と矛盾する主張も行い、弁護士報酬が更生債権になるかが争われた裁判例を論拠に次のように主張している。

これを本件における着手金についてみると、事件委任契約締結時に着手金の請求権は発生しており、更に、報酬金と異なり、その金額も定まっているのであるから、着手金の請求権自体は、事件委任契約締結時に確定しているというべきである。

【被告準備書面（7）8頁】

一方で慣習といいながら、ここでは更生債権事案の裁判例を引用して法的権利の確定があると主張していることになる。

まず、弁護士報酬の事案を着手金にそのまま適用していること自体誤っているし、しかも、更生債権性の有無の判断と、課税する状態になっているといえるかどうかの判断はおのずと異なる。さらに、何よりもこの裁判例も報酬債権の確保を図るために抽象的には権利の発生があるとしているにすぎず、収入金額として課税するのにふさわしいほど権利の実現があるとは全く述べているわけではない。現行法の36条は「収入すべき」時期を、多く取扱通達が認めているように、権利の実現があったといえる状態になった時点にしているのである。

おわりに・・・被告は課税要件を立証していない

以上述べたように、被告は最後の段階になって、着手金について慣習基準を持ち出して本件処分の適法性を維持しようとしている。

しかし、そうであるならば、慣習基準は、法的権利の確定ではないから、慣習に従って着手金を受領する場合でなければならない。従って、本件の場合、原告が契約締結時に現実にいくら受領していたかを立証しなければならないが、この点の立証はなされていない。

また、その前提として、弁護士が多重債務者に対する受任事案についても着手金を契約時に受領しているという慣習の存在も立証しなければならないが、この点の立証も全くなされていない。

このように、被告の主張は支離滅裂なものとなっているといわざるを得ない。